

1501250-76.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501250-76.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310809/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 21398251 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

4565/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2310809 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

4565/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FILIPE FACCHINI DE OLIVEIRA PIRES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

GABRIEL FILIPE FACCHINI DE OLIVEIRA PIRES e GABRIEL ROBERTO CARREIRA foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 15 de novembro de 2021, na Avenida Doutor Arnaldo Santos Cerdeira, nº 189, Planejada II, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com

unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, um aparelho celular Samsung Galaxy J5, de cor dourada, e a quantia de R\$ 463,00, pertencentes à vítima Alessandra Cristiane Luiz Medeiros.

Recebida a denúncia aos 22 de novembro de 2021 (fl. 104), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 115/122, 140 e 163/164).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 167), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas da acusação e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 204).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 208/214).

A defesa postulou o reconhecimento de atenuantes (confissão e menoridade) e a imposição de regime mais brando. A defesa de Gabriel Filipe pugnou, ainda, pela aplicação de causa de diminuição de pena – participação de menor importância – participe (fls. 217/235 e 256/260).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As autorias do delito imputado ficaram plenamente comprovadas.

Os acusados durante seus interrogatórios admitiram a prática da infração.

Suas confissões estão em harmonia com as demais provas. Senão vejamos.

A vítima Alessandra narrou que na ocasião dos fatos estava em seu estabelecimento comercial (Alex Dogs Parque) quando dois agentes adentraram ao local. Declarou que um deles estava com arma em punho. Posteriormente, eles anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular, assim como o dinheiro do caixa da empresa, fugindo em seguida.

Explicou que a polícia militar foi acionada e, depois dos policiais comparecerem ao local e obterem as características dos indivíduos, diligenciaram pelas proximidades, momento em que capturaram os agentes, localizando em poder deles os bens subtraídos, inclusive seu aparelho celular. Por fim, na Delegacia de Polícia os reconheceu como os indivíduos que perpetraram o roubo contra si.

Ora, a palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta dos acusados, merecendo credibilidade.

“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto”.

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DA RÉU. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pela testemunha arrolada pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. 2. A apreensão da "res" em poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício robusto da

autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as consequências do crime patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. 3. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 4. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do STF e do STJ. 5. Refazimento da dosimetria da pena. Manutenção do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa (crime cometido em concurso de agentes), o regime prisional refletindo intelecção do art. 33, § 3º, do Código Penal. 6. Parcial provimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00355702020128260554 SP 0035570-20.2012.8.26.0554, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 26/08/2015).

Por sua vez, o PM Alessandro relatou que foi acionado para atender a ocorrência de roubo em estabelecimento comercial, razão pela qual se dirigiu ao local. Lá chegando, entrevistou a vítima, que lhe informou o ocorrido e descreveu as características dos agentes. Diante disso, diligenciou pelas proximidades e localizou os acusados, que possuíam as mesmas características informadas pela vítima, razão pela qual os abordou.

Acrescentou que com Gabriel Filipe localizou dinheiro e o aparelho celular subtraídos da vítima; com Gabriel Roberto, um simulacro de arma de fogo. Indagados sobre o fato, ambos admitiram informalmente a prática da infração.

Suas palavras são confirmadas pelo PM Luiz Paulo, que de forma série e coerente certificou a captura dos acusados e o encontro da res furtiva em poder de um deles e um simulacro de arma de fogo na posse do outro, a par de suas admissões quanto à prática criminosa.

Nem se diga que o reconhecimento ocorrido perante a Autoridade Policial está emanado de nulidade, uma vez que as formalidades previstas na lei podem ser dispensadas quando é possível a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA À POSSE DO BEM ROUBADO PELO RÉU. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inexiste nulidade no reconhecimento do réu por fotografia na fase inquisitória quando há outros elementos de prova corroborando a condenação. 2. A palavra da vítima, de que reconheceu o réu por meio de foto, aliada ao fato do agente ter sido preso na posse direta da moto roubada, é suficiente para a condenação. 3. As circunstâncias judiciais devem ser analisadas em favor do agente quando não há elemento concreto apto a tornar a conduta mais gravosa do que aquela ínsita ao tipo. 4. Dispensa-se apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo. 5. Preliminar rejeitada, no mérito, dado parcial provimento ao recurso da defesa (2º) e provimento ao apelo ministerial (1º). TJ-MG - APR: 10024122102023001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/01/2014).

DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉUS POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. VALIDADE PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. NÃO APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO CONFIGURADO. 1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando se encontram acostadas aos autos peças comprobatórias da materialidade e da autoria do crime. 2. Aperícia da arma é dispensável à caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo suficiente a evidência por outras provas coligidas

aos autos, em especial, a palavra da vítima. 3. As formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP podem ser dispensadas quando é possível a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo. O reconhecimento fotográfico tem real valor probante quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório. 4. Se devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal. 5. Considerando que a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi satisfatoriamente justificada face à manutenção dos motivos que autorizaram a custódia cautelar da apelante, não merece ser acolhido o pedido para recorrer da sentença em liberdade. 6. Recurso da ré não provido. Recurso do réu parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20121110030460 DF 0002817-18.2012.8.07.0011, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 29/01/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 131).

Assente-se, ainda, que a apreensão do produto do roubo em poder dos acusados assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. Também não há que se falar em participação de menor importância, conforme pretende a defesa de Gabriel Filipe.

Ora, para a delimitação de sua culpabilidade, não é necessária a demonstração de que ele tenha praticado as elementares do tipo previsto no art. 157, do CP, haja vista que ele planejou e uniu esforços com o outro agente, concorrendo, assim, para a empreitada criminosa.

Gize-se que a vítima foi firme em narrar que ambos os acusados adentraram em seu estabelecimento comercial. Pouco importa que o simulacro de arma de fogo estivesse em poder de apenas um deles, uma vez que eles agiram de comum acordo e ali estavam para subtrair os bens da vítima. Acrescente-se, também, que quando da captura dos acusados, conforme relatos dos policiais, a res furtiva foi localizada com Gabriel Filipe e o simulacro, com Gabriel Roberto.

Destarte, Gabriel Filipe responde de igual forma pela ação, nos termos do art. 29, do Código Penal (teoria monista), considerando-se que ele e o coacusado atuaram em acordo de vontades, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, com todas as condutas possuindo relevância causal para a produção do resultado decorrente da prática do delito perpetrado.

Reza o Art. 29, do CP: Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade.

1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Em excepcional escólio, o insigne professor Rogério Greco ensina-nos que esse parágrafo somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa (GRECO, Rogério. Atividade Policial, aspectos penais, processuais penais, administrativos e constitucionais. Editora Impetus, 2ª edição, 2009, página 101).

Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em participação de menor importância.

Nesse mesmo sentido já decidiu o STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES PARA A PRÁTICA DELITIVA EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 6. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o

paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, com o fim de decotar o aumento da pena-base pela valoração negativa da personalidade e da conduta social do paciente para os crimes de roubo e posse de arma de fogo com numeração suprimida, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da reprimenda (HC 371.559/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 20-3-2018, v.i.).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. O Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista da participação (ou ainda Unitária ou Iguatária), a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria. Nesse contexto, deve ser esclarecido que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal. O conceito legal abrange também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração (autoria mediata), bem assim aquele que, ao partilhar da mesma intenção delitativa, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global. 5. No caso, constata-se que o Paciente agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu parceiro na empreitada, e que sua atuação foi determinante para a consecução de todos os delitos. Em outras palavras, o cometimento de crime único foi afastado devidamente, em virtude da união de propósitos e a relevância causal dos atos praticados pelo Paciente nos diversos resultados. Não é o caso de incidência, ademais, do art. 29, § 1.º, do Código Penal (reconhecimento da participação de menor importância), ou do § 2.º do mesmo artigo 6. Tem-se ainda que as instâncias ordinárias - soberanas na análise de fatos e provas -, reconheceram haver elementos probatórios coerentes e válidos para embasar o decreto condenatório do Paciente também quanto às demais condutas, motivo pelo qual não compete a esta Corte imiscuir-se em tal mérito para afastar essa conclusão. Dessa forma, a pretensão de reconhecer a prática de crime único mostra-se inviável na via do habeas corpus, diante da inevitável necessidade de aprofundado reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 7. No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018)" (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 598155 SC 2020/0176823-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Assim sendo, bem comprovadas as autorias, ficando sem guarida as combativas alegações da defesa.

A materialidade do delito está evidente diante do conjunto probatório elencado. O boletim de ocorrência (fls. 15/18), os autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 21/23 e 95) e o auto de prisão em flagrante, aliados às palavras da vítima e testemunhas demonstram a subsunção da conduta dos acusados ao tipo denunciado.

A prova testemunhal foi plena e está de acordo com o conjunto amealhado.

Em relação à causa de aumento descrita no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal: "se há concurso de duas ou mais pessoas", ela está demonstrada. Restou evidenciado que os agentes atuaram em unidade de ideais e mediante divisão de tarefas, visando o sucesso na empreitada criminosa.

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Suas condutas sociais e personalidades não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 4 (quatro) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda etapa, certificada a reincidência de Gabriel Roberto (fl. 64), observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas. Quanto à Gabriel Filipe, não obstante as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, suas penas já se encontram em seus limites mínimos, impedindo maior redução neste momento.

Causas especiais de diminuição não foram cogitadas na terceira fase.

Reconhecida uma causa de aumento, ensejando o roubo qualificado, não observo causas e motivos para que o aumento seja superior a 1/3 (4 anos + 1/3 = 5 anos e 4 meses/10 dias + 1/3 = 13 dias-multa).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado ante a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e com grave ameaça contra a pessoa.

"O regime fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais intranquilizadoras expressões da criminalidade nos tempos correntes".

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL.

DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO).

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. 1. A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa. Precedentes. 2.

Consoante dispõe o enunciado da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Desse modo, impõe-se a aplicação do quantum de aumento, em razão das majorantes do roubo, no grau mínimo legal, visto que a fração aplicada - 3/8 (três oitavos) - foi fundamentada, exclusivamente, em critério matemático, sem base em elementos concretos, entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 4. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso,

considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, a audácia do Paciente, que praticou os delitos, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em via pública e à noite, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta delituosa. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a fração da majorante, aplicada na terceira fase, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto. (STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para o crime de furto; b) fixação da pena base no mínimo; c) reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência; d) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e do policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. 3. Regime prisional fechado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - APR: 15072571220188260506 SP 1507257-12.2018.8.26.0506, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020)

Apelação. Crime de roubo. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma, fixando o regime fechado para início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso da Defesa visando: (i) afastar o emprego da majorante; (ii) o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. 1. A ausência de exame pericial na arma não obsta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, par.2º, I, do Código Penal. 2. Os dados empíricos da causa traduzem um grau de culpabilidade que impõem o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - APL: 00023261220148260108 SP 0002326-12.2014.8.26.0108, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 26/01/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2017).

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR GABRIEL FILIPE FACCHINI DE OLIVEIRA PIRES E GABRIEL ROBERTO CARREIRA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face suas condições econômicas.

A gravidade da infração e as penas aplicadas impedem qualquer forma de substituição de pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impedem a suspensão condicional da pena.

O sentenciado Gabriel Roberto não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Lado outro, Gabriel Filipe poderá apelar em liberdade, uma vez que se encontra nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Concedo a eles os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 12 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA